

المحاضرة الثالثة

المعاملات والوثائق والتوقيع الإلكتروني

مقدمة

لم يُعد التحول من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية مجرد تطور تقني في وسائل الاتصال، وإنما أصبح تحولاً في مفهوم المعاملة القانونية ذاتها؛ فالإرادة أصبحت يمكن أن تُعبر عنها إلكترونياً، والعقد يمكن أن يبرم دون اجتماع مادي بين طرفيه، والمستند يمكن أن يوجد في صورة رقمية، والتوقيع يمكن أن يكون خوارزمية تشفيرية بدلاً من أثر بالقلم، كما أصبحت الإدارة العامة قادرة على إصدار القرارات وحفظ الملفات ومباشرة الإجراءات عبر أنظمة إلكترونية.

ومن هنا ظهرت إشكالية قانونية جوهرية:

هل يمكن أن يتمتع الدليل الإلكتروني بذات القوة التي يتمتع بها الدليل الورقي؟ وإذا كان الجواب نعم، فما الضمانات القانونية والفنية التي تمنع التلاعب به وتثبت نسبته إلى صاحبه وسلامة محتواه؟

وقد أدرك المشرع العراقي هذه المسألة عندما أصدر قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٢، المنشور في الوقائع العراقية العدد (٤٢٥٦) في ٢٠١٢/١١/٥، وجعل من أهدافه توفير الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية وتعزيز الثقة بسلامتها .

المحور الأول: مفهوم المعاملات الإلكترونية

أولاً: المقصود بالمعاملة الإلكترونية:

عرّف المشرع العراقي في المادة (١) المعاملات الإلكترونية بأنها: الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية.

كما عرّف الوسائل الإلكترونية بأنها (أجهزة ومعدات أو أدوات كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في إنشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها)

وبذلك فإن المعاملة الإلكترونية لا تقتصر على العقد الإلكتروني، وإنما تشمل نطاقاً أوسع بكثير، مثل:

- تقديم الطلبات إلكترونياً .

- إبرام العقود .
- إصدار الفواتير .
- المراسلات الإلكترونية .
- الدفع الإلكتروني .
- تقديم العطاءات والمناقصات .
- إصدار الشهادات والموافقات .
- التوقيع على الوثائق .
- حفظ المستندات إلكترونياً .
- تبادل البيانات بين المؤسسات .
- التعاملات المصرفية الإلكترونية .

النتيجة المهمة هي :-

المعاملة الإلكترونية = إجراء قانوني أو إداري أو تجاري يتم كلياً أو جزئياً باستخدام وسيلة إلكترونية.

ثانياً: المبادئ القانونية الحاكمة للمعاملات الإلكترونية:

يمكن رد النظام الحديث للمعاملات الإلكترونية إلى ثلاثة مبادئ رئيسية اعتمدتها أعمال الأونسيترال:-

١. مبدأ عدم التمييز: لا يجوز حرمان المعلومات أو المعاملة من الأثر القانوني لمجرد أنها اتخذت شكلاً إلكترونياً.
٢. مبدأ التكافؤ الوظيفي: إذا استطاعت الوسيلة الإلكترونية تحقيق الوظيفة التي كان يؤديها المحرر الورقي، فيمكن منحها أثراً قانونياً مماثلاً.
٣. مبدأ الحياد التكنولوجي: القانون لا ينبغي أن يرتبط بتكنولوجيا محددة؛ لأن التكنولوجيا تتغير بسرعة.

وهذه المبادئ تشكل أساس قانون التجارة الإلكترونية الحديث وفق نموذج الأونسيترال للتجارة الإلكترونية لعام ١٩٩٦، الذي وضع قواعد الاعتراف بالمعلومات الإلكترونية والعقود والرسائل الإلكترونية .

ثالثاً: نطاق تطبيق القانون العراقي:

جاء القانون العراقي واسعاً في تحديد نطاقه، إذ يسري على المعاملات الإلكترونية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، وكذلك المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها إلكترونياً، فضلاً عن الأوراق المالية والتجارية الإلكترونية .

لكن المشرع العراقي لم يجعل هذا النطاق مطلقاً.

ومن أهم الاستثناءات:

- مسائل الأحوال الشخصية .
- إنشاء الوقف وتعديل أحكامه .
- التصرفات المتعلقة بالعقارات وحقوقها العينية، مع استثناء عقود إجبارها .
- المعاملات التي يشترط القانون لها شكلاً معيناً .
- إجراءات المحاكم والتبليغات القضائية .
- أوامر التفتيش والقبض والأحكام القضائية .
- الوثائق التي يشترط القانون توثيقها لدى الكاتب العدل .

ملاحظة قانونية مهمة

هذه الاستثناءات تكشف أن المشرع العراقي لم يتبنَّ مبدأ الرقمنة المطلقة، وإنما تبنى رقمنة المعاملات مع الإبقاء على بعض المجالات التي يرى فيها أن الشكلية التقليدية تحقق حماية قانونية خاصة.

المحور الثاني: الوثائق الإلكترونية

أولاً: مفهوم الوثيقة الإلكترونية:

عرّف القانون العراقي المستند الإلكتروني بأنها المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً أو البريد الإلكتروني أو الرق أو التلكس أو النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونياً

ومن الناحية الفنية يمكن أن تكون الوثيقة:

نصاً + بيانات وصفية + توقيعاً إلكترونياً + شهادة رقمية + ختم وقت + سجل تقني.

وهذا يقودنا إلى نقطة شديدة الأهمية:

الوثيقة الإلكترونية ليست مجرد ملف PDF.

فلا PDF قد يكون صورة لمحرر ورقي، وقد يكون مستنداً إلكترونياً منشأً أصلاً بصورة رقمية، وقد يكون موقعاً بتوقيع إلكتروني. والفرق بين هذه الحالات مهم جداً عند نظر النزاع أمام القضاء.

ثانياً: العناصر الفنية للوثيقة الإلكترونية:

لكي تكون الوثيقة الإلكترونية قابلة للاعتماد، ينبغي النظر إلى مجموعة من العناصر:

١. سلامة المحتوى Integrity : هل تعرض محتوى الوثيقة للتغيير بعد إنشائه؟
٢. الأصالة Authenticity : هل الوثيقة صادرة فعلاً عن الشخص أو الجهة المنسوبة إليها؟
٣. إمكانية التحقق Verification : هل توجد وسائل فنية تسمح بالتحقق من مصدر الوثيقة وتوقيعها؟
٤. إمكانية الوصول Accessibility : هل يمكن الرجوع إلى الوثيقة واستخدامها عند الحاجة؟
٥. قابلية القراءة والاسترجاع: هل يمكن فتحها وقراءتها بعد سنوات؟
٦. سلسلة الحيازة الرقمية Digital Chain of Custody (السجل الدقيق الذي يتتبع الدليل الإلكتروني من لحظة جمعه وتوثيقه وحتى عرضه أمام المحكمة لضمان سلامته وعدم التلاعب) يتضمن التسجيل الزمني والأشخاص القائمون عليه والحفظ والبصمة الرقمية .

يتضمن

من أنشأ الوثيقة؟

ومن استلمها؟

وأين حفظت؟

ومتى تم نقلها؟

وهل تم تعديلها؟

المحور الثالث: التوقيع الإلكتروني وحججه في الإثبات

أولاً: ما هو التوقيع الإلكتروني؟

عرف المشرع العراقي التوقيع الإلكتروني بأنه (علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع، ويكون معتمداً من جهة التصديق).

وبالتالي فإن التوقيع الإلكتروني ليس بالضرورة صورة لتوقيع الشخص بخط يده.

قد يكون: (رمزاً . رقم تعريف شخصي . شهادة رقمية . توقيعاً تشفيرياً . بصمة إلكترونية . وسيلة تحقق متعددة العوامل . أو تقنية أخرى تحقق الوظيفة القانونية للتوقيع) .

ثانياً: الوظائف القانونية للتوقيع:

التوقيع التقليدي يؤدي وظائف متعددة، أهمها:

- ١ . تحديد هوية الموقع .
- ٢ . التعبير عن الإرادة .
- ٣ . إثبات نسبة المحرر إلى صاحبه .
- ٤ . إظهار القبول بمضمون الوثيقة .
- ٥ . حماية الوثيقة من التغيير .

والتوقيع الإلكتروني الحديث يحاول تحقيق الوظائف ذاتها ولكن باستخدام وسائل تقنية.

ثالثاً: الحجية القانونية في القانون العراقي

تعد المادة (٤) من قانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٢ من أهم المواد في هذا المجال.

فالقانون يقرر صحة التوقيع الإلكتروني إذا أمكن تحديد هوية الموقع وبيان موافقته على ما ورد في الوثيقة الإلكترونية، وفق الكيفية المتفق عليها بين الموقع والمتلقي.

كما يمنح التوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، الحجية نفسها المقررة للتوقيع الخطي متى توافرت الشروط القانونية .

رابعاً: التوقيع الإلكتروني القوي من الناحية الإثباتية:

المادة (٥) من القانون العراقي تربط القوة الإثباتية للتوقيع الإلكتروني بمجموعة من الضمانات، من أهمها:

- ١ . ارتباط التوقيع بالموقع وحده: أي أن التوقيع يجب أن يكون مرتبطاً بشخص محدد.
- ٢ . سيطرة الموقع على وسيلة إنشاء التوقيع: يجب ألا تكون وسيلة إنشاء التوقيع متاحة للغير.

٣. إمكانية كشف التغيير: إذا جرى تعديل التوقيع أو البيانات المرتبطة به، يجب أن يكون بالإمكان اكتشاف ذلك.

٤. إنشاء التوقيع وفق الإجراءات المحددة قانوناً: أي أن الجانب الفني وحده لا يكفي، بل يجب أن يقتزن بالمتطلبات القانونية والتنظيمية .

خامساً: كيف يعمل التوقيع الرقمي فنياً؟

يمكن تبسيط العملية بالشكل التالي:

الوثيقة الإلكترونية -- خوارزمية التجزئة -- قيمة رقمية فريدة للوثيقة -- تشفير القيمة بالمفتاح الخاص -- التوقيع الإلكتروني -- التحقق بالمفتاح العام -- مقارنة قيمة التجزئة

إذا تطابقت القيمتان:

سلامة الوثيقة + صحة التوقيع

أما إذا اختلفتا:

هناك احتمال لتغيير الوثيقة أو التوقيع.

سادساً: الفرق بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي:

من المهم جداً عدم استخدام المصطلحين باعتبارهما مترادفين بصورة مطلقة.

Electronic Signature هو مفهوم قانوني واسع.

أما: Digital Signature فهو في الأصل مفهوم تقني يعتمد عادةً على تقنيات التشفير بالمفتاح العام. PKI

ومن هنا يمكن القول:

كل توقيع رقمي يمكن أن يكون توقيعاً إلكترونياً، لكن ليس كل توقيع إلكتروني توقيعاً رقمياً.

وهذا التمييز مهم جداً عند تقييم الدليل أمام القضاء.

المحور الرابع: الأرشفة الإلكترونية

أولاً: لماذا الأرشفة الإلكترونية مسألة قانونية وليست تقنية فقط؟

الخطأ الشائع هو النظر إلى الأرشفة باعتبارها مجرد: حفظ الملفات على الحاسوب". لكن الأرشفة القانونية تعني أكثر من ذلك، فالهدف هو ضمان أن تبقى الوثيقة:

موجودة + قابلة للقراءة + أصلية + سليمة + قابلة للتحقق + قابلة للاسترجاع طوال المدة التي يفرضها القانون.

ثانياً: دورة حياة الوثيقة الإلكترونية

يمكن تصور دورة حياة الوثيقة بالشكل الآتي:

إنشاء -- توقيع -- تسجيل -- تصنيف -- حفظ -- مراقبة سلامة المحتوى

استرجاع عند الحاجة -- إتلاف قانوني آمن بعد انتهاء مدة الحفظ

ثالثاً: متطلبات الأرشفة القانونية والفنية

ينبغي أن يتوافر في نظام الأرشفة:

أ. سلامة المحتوى: منع التعديل غير المصرح به.

ب. التحكم في الصلاحيات: ليس كل موظف يستطيع الدخول إلى كل الوثائق.

ج. سجل الدخول والتعديل Audit Trail : معرفة:

- من دخل؟
- متى دخل؟
- ماذا فعل؟
- هل قام بالتعديل أو الحذف؟

د. النسخ الاحتياطي: وجود نسخ احتياطية متعددة وآمنة.

هـ. التشفير: خصوصاً للوثائق الحساسة.

و. الختم الزمني الإلكتروني: لتحديد زمن وجود الوثيقة والتوقيع عليها.

ز. قابلية الاسترجاع: يجب أن تكون الوثيقة قابلة للاسترجاع حتى بعد مرور سنوات.

رابعاً: اتجاه القانون المقارن

في الاتحاد الأوروبي، توسع الإطار القانوني الحديث ليشمل خدمات الثقة والأرشفة الإلكترونية؛ كما أن قواعد المقررة تتضمن عدم جواز رفض الوثيقة الإلكترونية لمجرد كونها إلكترونية، وتضع تنظيمات لخدمات الأرشفة الإلكترونية المؤهلة، أما الإمارات فقد جعلت حفظ الوثائق الإلكترونية جزءاً صريحاً من تنظيم المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وهو اتجاه جدير بالمقارنة مع التشريع العراقي .

المحور الخامس: الإثبات في البيئة الرقمية

أولاً: التحول من "الدليل الورقي" إلى "الدليل الرقمي":

القاضي في البيئة التقليدية يتعامل مع:

- محرر ورقي .
- توقيع خطي .
- ختم .
- أصل وصورة .

أما في البيئة الرقمية فقد يواجه:

- ملف PDF .
- بريد إلكتروني .
- رسالة هاتفية .
- قاعدة بيانات .
- سجل دخول .
- عنوان IP .
- توقيعاً رقمياً .
- شهادة رقمية .
- Metadata .

- سجل . Block chain
- تسجيل كاميرا .
- سجل خادم . Server Log

وهنا تظهر المشكلة: كيف يطمئن القاضي إلى أن الدليل الرقمي لم يتغير؟

ثانياً: معايير تقييم الدليل الإلكتروني:

أقترح اعتماد خمسة معايير قضائية رئيسية:

١. الأصالة Authenticity : هل الدليل منسوب فعلاً إلى مصدره؟
٢. السلامة Integrity : هل بقي محتوى الدليل دون تغيير؟
٣. الموثوقية Reliability : هل النظام الذي أنشأ الدليل نظام موثوق؟
٤. إمكانية التحقق Verification : هل يمكن للخبير أو المحكمة التحقق من مصدره وسلامته؟
٥. سلسلة الحيازة Chain of Custody : هل تم الحفاظ على الدليل منذ الحصول عليه وحتى تقديمه أمام المحكمة؟

ثالثاً: البريد الإلكتروني كدليل:

مثلاً: إذا قدم أحد الخصوم بريداً إلكترونياً باعتباره دليلاً على إبرام عقد، فلا ينبغي أن يكون السؤال: هل هذه رسالة إلكترونية؟

بل ينبغي أن تكون الأسئلة:

- من أرسلها؟
- إلى من؟
- متى أرسلت؟
- هل الحساب تابع فعلاً للمرسل؟
- هل تعرضت الرسالة للتعديل؟
- هل توجد سجلات الخادم؟
- هل توجد رسائل مرتبطة بها؟
- هل توجد قرائن أخرى تؤيدها؟
- هل تم استخراجها بطريقة فنية سليمة؟

وهذا ينقل عملية الإثبات من مجرد قراءة المستند إلى فحص البيئة الرقمية التي أنشأت المستند.

رابعاً: الخبير الفني ودور القضاء:

في المنازعات الرقمية، لا ينبغي للفاضي أن يتحول إلى مهندس شبكات أو خبير تشفير، ولكن ينبغي أن يكون قادراً على فهم:

١. ما الذي يجب إثباته قانوناً؟
٢. وأن يستعين بالخبير للإجابة عن:
٣. كيف يمكن إثباته فنياً؟

وهذه نقطة جوهرية في العلاقة بين القانون والتكنولوجيا.

إشكالية مهمة في التشريع العراقي: قانون رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٢ يقرر:

- الاعتراف بالمعاملات الإلكترونية .
- الاعتراف بالوثائق الإلكترونية .
- الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني .
- منح التوقيع الإلكتروني حجية التوقيع الخطي في نطاق محدد .
- تنظيم شهادات التصديق .
- تنظيم جهات التصديق .
- وضع شروط للقوة الإثباتية للتوقيع .

يمكن تسجيل ملاحظة نقدية مهمة:

المشرع العراقي سبق أن وضع الأساس التشريعي للمعاملات والتوقيع الإلكتروني منذ عام ٢٠١٢، إلا أن التطور التقني اللاحق أوجد حاجات تنظيمية جديدة تتجاوز مجرد الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني.

فبيئة اليوم تحتاج إلى تنظيم أكثر تفصيلاً:

- الهوية الرقمية .
- التوقيع الإلكتروني المؤهل .
- الختم الإلكتروني .
- الختم الزمني .

- خدمات الثقة .
- الحفظ والأرشفة الرقمية .
- الأدلة الرقمية .
- السجلات الإلكترونية .
- الحوسبة السحابية .
- الذكاء الاصطناعي .
- الأنظمة المؤتمتة .
- الأمن السيبراني .
- حماية البيانات .
- الاعتراف العابر للحدود بالتوقيعات والشهادات .

وهذا يتفق مع الاتجاه الدولي الذي انتقل من مجرد "التوقيع الإلكتروني" إلى منظومة أوسع هي Digital Trust خدمات الثقة الرقمية . وقد تطورت أعمال الأونسيترال نفسها لاحقاً لتشمل إدارة الهوية وخدمات الثقة والسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وغيرها .

نموذج تطبيقي يمكن طرحه (لنفترض أن شركة أرسلت إلى شركة أخرى عقداً إلكترونياً بقيمة مليار دينار، وتم توقيعه إلكترونياً). بعد سنة حصل نزاع. تقول الشركة الأولى " هذا العقد موقع إلكترونياً". وترد الشركة الثانية : لم أوقعه".

هنا لا ينبغي أن يكون السؤال القضائي: هل العقد إلكتروني؟

بل: السؤال الأول هل الوثيقة أصلية؟

السؤال الثاني هل التوقيع مرتبط بالشخص المدعى صدوره عنه؟

السؤال الثالث هل كانت وسيلة التوقيع تحت سيطرته؟

السؤال الرابع هل تم تعديل العقد بعد التوقيع؟

السؤال الخامس هل الشهادة الرقمية كانت نافذة وقت التوقيع؟

سؤال السادس هل يوجد ختم زمني؟

سؤال السابع هل توجد سجلات تقنية تؤيد عملية التوقيع؟

السؤال الثامن هل يمكن للخبير الفني إعادة التحقق من التوقيع؟

وبذلك نصل إلى القاعدة:

الدليل الإلكتروني لا تثبت قوته من شكله الإلكتروني، وإنما من درجة موثوقية البيئة التقنية والقانونية التي أنشأته وحفظته.